

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1452/2530

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ฯ  
นายหงษ์ สุขเกษม กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 40, มาตรา 197 วรรคสอง, มาตรา 243

คำร้องขอเลื่อนคดีของจำเลยอ้างว่าจำเลยติดธุระสำคัญ ไม่อาจมาศาลได้เพราะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหลายวัน แต่ไม่ปรากฏว่าทนายจำเลยติดธุระอะไร สำคัญเพียงใดจนไม่อาจมาศาลได้และจำเป็นอย่างไรต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหลายวัน รวมทั้งไปจังหวัดไหน ห้างไกลศาลเท่าไร เป็นการกล่าวอ้างลอยๆ ไม่มีเหตุผลสมควรจะสั่งให้เลื่อนคดี ถึงวันนัดพิจารณาจำเลยก็ไม่มาศาลดังนี้เห็นได้ว่าจำเลยประวิงคดีศาลชั้นต้นชอบที่จะสั่งไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีและให้สืบพยานโจทก์ไปในนัดนั้นได้

การดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ศาลจะมีคำสั่งว่าคู่ความฝ่ายใดขาดนัดพิจารณาย่อมจะมีได้เพียงกรณีเดียวดังที่บัญญัติไว้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 197 วรรคสอง เมื่อปรากฏว่าในวันสืบพยานฝ่ายจำเลยไม่มาศาล แต่ทนายจำเลยได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีไว้ก่อนวันสืบพยานแล้ว จึงถือได้ว่าคู่ความซึ่งเป็นฝ่ายจำเลยได้ร้องขอเลื่อนคดี หรือได้แจ้งเหตุขัดข้องที่มาศาลไม่ได้ให้ศาลทราบก่อนลงมือสืบพยานแล้ว ไม่ใช่กรณีที่จำเลยไม่มาศาลและไม่แจ้งเหตุขัดข้องอันจะถือว่าเป็นการขาดนัดพิจารณา การที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดี และมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาโดยสืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียว และพิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบ เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบศาลฎีกามีอำนาจยกคำพิพากษาศาลชั้น

ต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณา โดยสืบพยานจำเลยแล้วพิพากษาใหม่ได้.  
(ที่มา-สงเสริม)

---

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้ตามสัญญาอัยมค้ำประกันและ  
จำนองให้แก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์ไม่มีสิทธิติดดอกเบี้ยยทบต้น  
และจำเลยทั้งสองไม่เคยได้รับคำบอกกล่าวบังคับจำนองขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยทั้งสองขาดนัดพิจารณาศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระ  
เงิน 82,956.29 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีในต้นเงินดังกล่าว ตั้งแต่  
วันที่ 16 เมษายน 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระหนี้ให้โจทก์เสร็จ  
หากจำเลยทั้งสองไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ ก็ให้ยึดทรัพย์สินจำนองออกขายทอด  
ตลาดชำระหนี้ให้โจทก์ หากเงินจากการขายทอดตลาดได้ไม่พอชำระหนี้ ก็ให้ยึด  
ทรัพย์สินของจำเลยที่ 2ชำระหนี้จนครบ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชา  
ธรรมเนียมโดยกำหนดค่าทนายความ 2,500 บาทแทนโจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งและคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นดำเนิน  
กระบวนการพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดีค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้ศาลชั้นต้น  
รวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่

## โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงปรากฏว่าศาลชั้นต้นนัดสืบพยานโจทก์ วันที่ 27 ธันวาคม 2526 จำเลยยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2526 ขอเลื่อนคดีอ้างว่าทนายจำเลยติดธุระสำคัญไม่อาจมาศาลได้ เพราะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหลายวัน ศาลชั้นต้นสั่งว่าสำเนาให้โจทก์ จะส่งคำร้องในวันนัดพิจารณา เมื่อถึงวันนัดพิจารณาฝ่ายโจทก์มาศาล ฝ่ายจำเลยทั้งสองไม่มาศาลเลย โจทก์แถลงว่าจำเลยที่ 1 ประวิงคดี ศาลชั้นต้นเห็นว่าจำเลยที่ 1 ประวิงคดีจึงไม่อนุญาตให้จำเลยที่ 1 เลื่อนคดี เมื่อจำเลยที่ 1 ไม่มาศาล จึงถือว่าจำเลยที่ 1 ขาดนัดพิจารณา ส่วนจำเลยที่ 2 ก็ไม่มาศาล ก็ถือว่าจำเลยที่ 2 ขาดนัดพิจารณาด้วย สืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียวและพิพากษาให้จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบฟ้อง ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าคำร้องของจำเลยทั้งสองซึ่งขอเลื่อนคดีมีเหตุสมควรหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คำร้องขอเลื่อนคดีของจำเลยทั้งสองอ้างว่าทนายจำเลยติดธุระสำคัญ ไม่อาจมาศาลได้ เพราะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหลายวันนั้น ไม่ปรากฏว่าทนายจำเลยติดธุระอะไรสำคัญเพียงใดจนไม่อาจมาศาลได้ และจำเป็นอย่างใดต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหลายวัน รวมทั้งไปจังหวัดไหน ห่างไกลศาลอย่างไร เป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่มีเหตุผลสมควรที่จะสั่งให้เลื่อนคดี ถึงวันนัดตัวจำเลยทั้งสองก็ไม่มาศาล ดังนั้นเห็นได้ว่าจำเลยทั้งสองประวิงคดีที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี และสืบพยานโจทก์ในนัดนี้จึงชอบแล้ว ปัญหาต่อไปมีว่า การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยทั้งสองขาดนัดพิจารณา และได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยขาดนัด จะเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยชอบหรือไม่นั้น เห็นว่า การดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ศาลจะมีคำสั่งว่าคู่ความฝ่ายใดขาดนัดพิจารณา ย่อมจะมีได้ก็เพียงกรณีเดียวดังที่บัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 197 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติไว้ว่า "ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลในวันสืบพยาน และมีได้ร้องขอ

เลื่อนคดีหรือแจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่มาศาลเสียก่อนลงมือสืบพยานให้ถือว่าคู่ความฝ่ายนั้นขาดนัดพิจารณา" กรณีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าทนายจำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีก่อนวันสืบพยานโจทก์ซึ่งในกรณีดังกล่าวศาลฎีกาเห็นว่า ย่อมจะถือได้ว่าคู่ความซึ่งเป็นฝ่ายจำเลยได้ร้องขอเลื่อนคดี หรือได้แจ้งเหตุขัดข้องที่มาศาลไม่ได้ให้ศาลทราบก่อนลงมือสืบพยานแล้วไม่ใช่กรณีที่ไม่นำศาลและไม่แจ้งเหตุขัดข้องอันจะถือได้ว่าเป็นการขาดนัดพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 197 วรรคสอง ศาลฎีกาเห็นสมควรให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาเริ่มแต่การสืบพยานจำเลยเป็นต้นไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยสืบพยานจำเลยทั้งสองแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่".

(สาระ เสาวมล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

หลักเกณฑ์ที่ศาลจะสั่งให้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขาดนัดพิจารณาตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 197 วรรคสอง ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์

3 ประการคือ 1. คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาล 2. เป็นการไม่มาศาลในวันสืบพยานนัดแรก และ 3. มิได้ร้องขอเลื่อนคดีหรือแจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่มาศาลเสียก่อนลงมือสืบพยาน คำว่า "คู่ความ" ตามหลักเกณฑ์ข้อแรกหมายถึง บุคคลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(11) ได้แก่โจทก์จำเลย ผู้ร้องขอทรัพย์ บุคคลผู้มีสิทธิทำการแทนบุคคลดังกล่าว เช่นผู้แทนนิติบุคคล ผู้อนุบาล ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้รับมอบอำนาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งกระทำการแทนผู้ล้มละลาย ผู้แทนเฉพาะคดีตามมาตรา 56 วรรคท้าย และทนายความ การที่ศาลจะสั่งให้คู่ความฝ่ายใดขาดนัดพิจารณาได้ต้องเป็นเรื่องไม่มีผู้ใดมาศาลเลย ฉะนั้นหากตัวความไม่มาศาลแต่ทนายความมา ก็จะถือว่าขาดนัดพิจารณาไม่ได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 467/2486) หลักเกณฑ์ข้อ 2 เป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วว่า การไม่มาศาลนั้นต้องเป็นการไม่มาศาลในวันที่ศาลเริ่มต้นทำการสืบพยานกันจริงๆ โดยไม่มีการอนุญาตให้เลื่อนคดีเท่านั้นส่วนวันอื่นเช่นวันนัดพร้อมหรือวันนัดชี้สองสถานไม่ถือเป็นวันสืบพยาน แม้คู่ความไม่มาศาลในวันดังกล่าวก็ไม่ถือว่าขาดนัดพิจารณา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1318/2495) และวันเริ่มต้นทำการสืบพยานนี้หมายถึงวันสืบพยานนัดแรกฉะนั้น แม้คู่ความฝ่ายใดจะไม่มีหน้าที่นำสืบในวันนั้น หากไม่มาศาลศาลก็อาจสั่งว่าขาดนัดพิจารณาได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 863/2504(ประชุมใหญ่) และหากคู่ความฝ่ายใดมาศาลในวันนัดสืบพยานนัดแรกที่มีการสืบพยานกันจริง ๆ แล้ว แม้ในนัดต่อ ๆ มาจะไม่มาศาล ศาลก็จะสั่งว่าขาดนัดพิจารณาไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 543/2503, 1496/2518 และ 1510/2510) หลักเกณฑ์ข้อ 3 กล่าวโดยย่อคือการที่คู่ความไม่มาศาลในวันสืบพยานอันจะถือว่าเป็นการขาดนัดพิจารณาได้นั้น ต้องเป็นเรื่องที่คู่ความนั้นมิได้ร้องขอเลื่อนคดีหรือแจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่มาศาลเสียก่อนลงมือสืบพยาน หากไม่มาศาลแต่ได้ขอเลื่อนคดีหรือแจ้งเหตุขัดข้องต่อศาลไว้ก็จะถือว่าคู่ความนั้นขาดนัดไม่ได้ และมีข้อนำพิจารณาดังนี้ 1. หากตัวความหรือทนายความมาศาลในวันนัดสืบพยานนัดแรกและยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี แต่ศาลสั่งไม่อนุญาต มี

ปัญหาว่าศาลจะสั่งว่าคู่ความฝ่ายนั้นขาดนัดพิจารณาได้หรือไม่ ข้อนี้คงเป็นที่ยอมร่วมกันว่า ศาลจะสั่งว่าขาดนัดพิจารณาไม่ได้เพราะเป็นกรณีที่คู่ความมาศาลไม่เข้าหลักเกณฑ์ในข้อ 1 ดังกล่าวแล้ว 2. หากตัวความและทนายความไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานนัดแรก แต่ทนายความได้มอบฉันทะให้เสมียนทนายนำคำร้องขอเลื่อนคดีมายื่นต่อศาลกรณีเช่นนี้ศาลก็จะสั่งว่าคู่ความฝ่ายนั้นขาดนัดพิจารณาไม่ได้แม้ว่าจะสั่งไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีก็ตาม เพราะไม่ใช่กรณีจำเลยไม่มาศาลและไม่แจ้งเหตุขัดข้อง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1721/2524) 3. กรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ ปราบฎว่าจำเลยทั้งสองไม่มาศาลในวันนัดสืบพยาน แต่จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีไว้ก่อนวันสืบพยาน ซึ่งศาลเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควรที่จะสั่งให้เลื่อนคดีเพราะจำเลยทั้งสองประวิงคดี เช่นนี้ศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยได้ร้องขอเลื่อนคดีหรือได้แจ้งเหตุขัดข้องที่มาศาลไม่ได้ให้ศาลทราบก่อนลงมือสืบพยานแล้ว ไม่ใช่กรณีที่ไม่มาศาลและไม่แจ้งเหตุขัดข้อง จึงมีปัญหาคิดว่าการร้องขอเลื่อนคดีหรือการเกิดเหตุขัดข้องที่ไม่มาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 197 วรรคสองจะต้องมีเหตุผลอันสมควรด้วยหรือไม่ หรือเพียงแต่ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีหรือแจ้งเหตุขัดข้องไว้ก่อน แม้จะไม่มีเหตุผลอันสมควร ศาลก็ไม่อาจสั่งว่าคู่ความฝ่ายนั้นขาดนัดพิจารณาได้ ปัญหานี้ หากแปลความเคร่งครัดตามตัวอักษร จะเห็นว่าหากปรากฏว่าความได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีหรือแจ้งเหตุขัดข้องไว้แล้วและไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานศาลจะสั่งว่าคู่ความฝ่ายนั้นขาดนัดพิจารณาไม่ได้ ไม่ว่าการขอเลื่อนคดีหรือแจ้งเหตุขัดข้องนั้นจะมีเหตุผลอันสมควรหรือไม่ก็ตาม ซึ่งผู้บันทึกเห็นว่าไม่น่าจะแปลกฎหมายบทมาตราดังกล่าวเคร่งครัดตามตัวอักษร แต่น่าจะแปลว่าคำร้องขอเลื่อนคดีหรือการแจ้งเหตุขัดข้องดังกล่าวต้องมีเหตุผลอันสมควรด้วยเสมอซึ่งน่าจำต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายมากกว่า มิฉะนั้นจะเป็นช่องทางให้คู่ความอาศัยการแปลความโดยเคร่งครัดดังกล่าวทำการประวิงคดีได้โดยง่าย ทั้งนี้เพราะเมื่อศาลไม่อาจสั่งว่าขาดนัดพิจารณาได้ศาลก็จะสั่งให้พิจารณาคดีไปฝ่ายเดียวหาได้ไม่ อย่างเช่นในคดีนี้

เมื่อศาลให้สืบพยานโจทก์ไปในวันนัดสืบพยานโจทก์แล้วศาลก็ต้องสั่งให้เลื่อนคดีไปเพื่อนัดสืบพยานจำเลย เพราะจำเลยได้ยื่นคำให้การไว้แล้วจำเลยคงเสียโอกาสเพียงไม่ได้ซักค้านพยานโจทก์ในนัดที่ศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีเท่านั้น และในกรณีเช่นนี้แม้ศาลจะเห็นว่าจำเลยประวิงคดี แต่จะสั่งงดสืบพยานจำเลยเสียในวันสืบพยานโจทก์ดังกล่าวก็ทำไม่ได้ เพราะศาลไม่ได้นัดสืบพยานจำเลยไว้ และจะถือว่าจำเลยไม่มีพยานมาสืบก็ไม่ได้เช่นกันเนื่องจากจำเลยไม่มีหน้าที่นำพยานมาสืบในวันนั้น มีปัญหานำพิจารณาต่อไปว่า หากคดีนี้ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องขอเลื่อนคดีของจำเลยทั้งสองในวันที่จำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีทันทีโดยไม่รอสั่งในวันนัดและศาลสั่งในวันนั้นว่าไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีเพราะจำเลยประวิงคดี เช่นนี้จะทำให้มีผลเปลี่ยนแปลงไปเมื่อถึงวันนัดสืบพยานโจทก์หรือไม่ ปัญหานี้ผู้บันทึกเห็นว่าเมื่อแปลว่าการขอเลื่อนคดีหรือแจ้งเหตุขัดข้องต่อศาลจะต้องมีเหตุสมควรด้วยกล่าวคือจะต้องเป็นเรื่องที่ศาลอนุญาตให้เลื่อนคดี หรือเห็นว่าขัดข้องนั้นมีเหตุผลอันสมควรเท่านั้นแล้ว ศาลก็น่าที่จะสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาในวันสืบพยานโจทก์ได้ ประกอบกับคำร้องขอเลื่อนคดีของจำเลยศาลได้สั่งในวันที่จำเลยยื่น จำเลยย่อมทราบอยู่แล้วว่าศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีด้วยเหตุที่อ้างในคำร้องนั้น เช่นนี้ผู้บันทึกเห็นว่าคำร้องขอเลื่อนคดีดังกล่าวของจำเลยย่อมตกไปและจำเลยยังทราบวันนัดสืบพยานโจทก์เดิมอยู่เพราะแม้จำเลยจะไม่รอฟังคำสั่งศาลในวันนั้น ก็ถือว่าจำเลยทราบคำสั่งแล้ว (ตามแบบฟอร์มคำร้องของศาลที่จำเลยยื่น) จำเลยไม่อาจอ้างว่าตนไม่ขาดนัดพิจารณาเพราะเหตุที่ได้มีการยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีไว้แล้วได้อีก อย่างไรก็ตามก็ดีทางแก้ที่ศาลจะสั่งคำร้องขอเลื่อนคดีของจำเลยในวันที่ยื่นคำร้องอาจไม่สามารถแก้ข้อขัดข้องในความล่าช้าของกระบวนการพิจารณาคดีได้สัมฤทธิ์ผลเพราะทนายจำเลยอาจมอบฉันทะให้เสมียนทนายนำคำร้องขอเลื่อนคดีโดยอ้างเหตุอื่นมายื่นต่อศาลในวันนัดสืบพยานอีก และศาลก็ไม่อาจสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาได้ ไม่ว่าคำร้องขอเลื่อนคดีนั้นจะมีเหตุอันสมควรหรือไม่ ทั้งนี้ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1721/2524 ดังกล่าวแล้วข้างต้น แต่ถ้าหากเรายึดหลัก

การแปลความหมายของคำว่า "ร้องขอเลื่อนคดีหรือแจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่มาศาล" ว่าจะต้องมีเหตุผลอันสมควรด้วยเสมอแล้ว ปัญหาความล่าช้าของกระบวนการพิจารณาก็อาจจะหมดไปได้ส่วนหนึ่งเพราะเมื่อศาลเห็นว่าคำร้องขอเลื่อนคดีหรือเหตุขัดข้องที่แจ้งมาก่อนลงมือสืบพยานนั้นไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งถือเท่ากับว่าคู่ความฝ่ายนั้นมีได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีหรือแจ้งเหตุขัดข้อง และคู่ความฝ่ายนั้นไม่มาศาล ศาลย่อมสั่งว่าขาดนัดพิจารณา และสามารถดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีไปฝ่ายเดียวได้ อย่างไรก็ตามก็ดี เกี่ยวกับปัญหานี้มีคำพิพากษาศาลฎีกา 1077/2519วินิจฉัยว่า ทนายโจทก์ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีในวันนัดสืบพยาน แต่ไม่มาศาลในวันนัด ศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี ถือว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาและตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 201 เมื่อโจทก์ขาดนัดพิจารณา ให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นเสียจากสารบบความเว้นแต่จำเลยจะได้แจ้งต่อศาลว่าตนตั้งใจจะให้ดำเนินการพิจารณาคดีต่อไป เรื่องนี้ศาลฎีกายังได้ให้ความเห็นไว้ด้วยว่า แม้ทนายโจทก์จะได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนการพิจารณา แต่เมื่อศาลสั่งไม่อนุญาต ก็ยังมีการนัดสืบพยานอยู่ และแม้ทนายโจทก์จะมาศาลในวันนั้นโดยมายื่นคำร้องขอเลื่อนการพิจารณาต่อเจ้าพนักงานศาลแต่ไม่อยู่เพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณา ก็ต้องถือว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณา 4. มีข้อน่าสังเกตว่าการที่ศาลสั่งว่าคู่ความฝ่ายใดขาดนัดพิจารณา บางครั้งกลับส่งผลดีให้แก่คู่ความฝ่ายนั้นมากกว่าที่ศาลจะเห็นว่าคู่ความฝ่ายนั้นไม่ขาดนัดพิจารณา อย่างไรก็ตามในคดีนี้หากในวันสืบพยานโจทก์ศาลได้นัดสืบพยานจำเลยไว้ด้วย เมื่อศาลสั่งไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี แม้จะสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาไม่ได้ แต่ศาลก็จะดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์ไป เมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จทางฝ่ายจำเลยไม่มีผู้ใดมาศาล ก็ถือได้ว่าจำเลยไม่มีพยานมาสืบ ศาลย่อมสั่งงดสืบพยานจำเลยได้ และเป็นที่แน่นอนว่าศาลคงต้องพิพากษาให้จำเลยแพ้คดีเช่นนี้คำพิพากษาของศาลชั้นต้นก็มีลักษณะเป็นการวินิจฉัยลงไปในเรื่องแล้วมิใช่การพิพากษาให้แพ้คดีโดยคู่ความขาดนัดพิจารณาทางแก้ไขของจำเลยก็มีทางเดียวคือต้องอุทธรณ์ต่อไปยังศาลอุทธรณ์หากคดีนั้นไม่ต้องห้าม



อุทธรณ์ตามกฎหมาย ซึ่งผลเสียย่อมตกแก่จำเลยเป็นแน่เพราะโอกาสที่จำเลยจะชนะคดีมีได้น้อยมาก และจำเลยจะมายื่นคำร้องว่าไม่พอใจขาดนัด ขอให้พิจารณาคดีใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 207,208 ก็ทำไม่ได้เพราะศาลไม่ได้สั่งแสดงว่าจำเลยขาดนัดและพิพากษาให้จำเลยแพ้คดีในประเด็นที่พิพาทเพราะเป็นเหตุขาดนัด(ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3003/2527 ประกอบ) หรือในกรณีที่ศาลนัดสืบพยานจำเลยเป็นนัดแรก และฝ่ายจำเลยไม่มีผู้ใดมาศาล แต่ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีไว้ก่อน ซึ่งศาลสั่งไม่อนุญาต ผลก็จะเป็นเช่นเดียวกันกล่าวคือ แม้ศาลจะพิจารณาคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียวไม่ได้ เพราะไม่ได้สั่งให้จำเลยขาดนัดพิจารณา แต่ศาลก็สั่งงดสืบพยานจำเลยและนัดสืบพยานโจทก์ต่อไปได้ ซึ่งจำเลยก็จะต้องตกเป็นฝ่ายแพ้คดีเช่นกันและไม่อาจขอพิจารณาคดีใหม่เพื่อตั้งหลักเตรียมคดีใหม่ได้. ประโยชน์ ดีผดุง